



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 902195 - RS (2024/0110552-3)

RELATOR : MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
IMPETRANTE : LUIZ GUSTAVO PUPERI
ADVOGADO : LUIZ GUSTAVO PUPERI - RS064134
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE : MARIZAN DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS : LUIZ GUSTAVO PUPERI - RS064134
IVANDERSON DA SILVA ALBUQUERQUE - DF059045
CORRÉU : GILBERTO DE SOUZA TAMBASCO
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO

Cuida-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARIZAN DE FREITAS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL proferido no julgamento do HC n. 5064770-67.2024.8.21.7000/RS.

Extraí-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Parobé/RS pronunciou o paciente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 61, I, e com o art. 62, I, na forma do art. 29, *caput*, todos do Código Penal - CP (homicídio qualificado).

Em 1º/3/2024, foi indeferido pedido que tencionava o reconhecimento de nulidade de elementos de convicção existentes nos autos da ação penal, com a consequente despronúncia do paciente, além do reconhecimento do excesso de prazo da custódia cautelar (fls. 3.061/3.069).

Irresignado, o paciente impetrou *habeas corpus* perante a Corte de origem objetivando a anulação de provas e a sua despronúncia, assim como a revogação da custódia, contudo, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul conheceu em parte do *writ* e, na parte conhecida, denegou a ordem, nos termos do acórdão de fls. 123/128, que restou assim ementado:

"HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERICULUM LIBERTATIS CONTEMPORÂNEO DEMONSTRADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIAL PROBATÓRIO ÍNTEGRO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PRECLUSA.

IMPOSSIBILIDADE DE CONTESTAÇÃO.

1. O paciente possui um extenso histórico criminal, estando em cumprimento de uma pena total de 43 anos e 07 meses de reclusão, com saldo de mais de vinte e nove anos a cumprir. Não somente isso, quando recentemente agraciado com a prisão domiciliar, buscou se furtar tanto da execução de sua pena, quanto de sua responsabilização criminal em processos pelos quais está respondendo. Na oportunidade, a sua fuga se tornou notória, tendo sido localizado quando estava no estado de São Paulo, com informações obtidas pela Secretaria de Segurança Pública de que orquestrava a saída do Brasil para o Peru. Todas condições somadas expõem a periculosidade em concreto do paciente. Sob outro aspecto, não prospera a alegação de excesso de prazo à formação da culpa do paciente. Isso porque a delonga no feito tem se dado diante do cumprimento de diligências requeridas pela própria defesa, as quais estão sendo, inclusive, efetivadas em tempo hábil pelo Juízo a quo e demais autoridades competentes para o prosseguimento do feito e submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A busca defensiva pela declaração de ilicitude das provas obtidas pelo resultado da extração de dados e, posterior, despronúncia do acusado, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, revela-se inexequível diante do quadro fático apresentado, bem como em face da inviabilidade de se aprofundar em questões de mérito em sede de habeas corpus. Importa ressaltar a existência de uma dificuldade operacional em afastar um juízo de pronúncia formado pelo juízo a quo e confirmado por esta Corte de Justiça. No mais, apesar da impossibilidade atual de acesso aos elementos de prova objetos de contestação, não se pode presumir a ilegalidade dos relatórios e da extração de dados operada, posto que produzidos à época em que não se exigia a adoção de procedimento específico para a sua realização. Logo, não há como se ignorar o significativo lapso temporal entre a apreensão do telefone celular - quando sequer eram regulamentados os procedimentos atinentes à cadeia de custódia - e a pretensão de acesso pela defesa aos dados constantes nele. Com efeito, sendo a irresignação defensiva direcionada à decisão de pronúncia, a qual restou confirmada por este Tribunal de Justiça, a controvérsia aqui despertada não pode ser deduzida por habeas corpus na mesma instância confirmatória do ato de pronúncia. Tal circunstância demanda o não conhecimento da impetração no ponto, seja pela inadequação da medida quanto ao endereçamento de sua contestação, como também pela preclusão da matéria, em face do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA." (fls. 127/128).

Neste *habeas corpus*, a defesa aduz, em síntese, a configuração de flagrante ilegalidade consistente na manutenção da pronúncia do paciente com base em provas

alegadamente inidôneas, que não observaram os parâmetros relativos à cadeia de custódia.

Assevera que não foram preservadas as evidências digitais que subsidiam a imputação, como comprovado em laudo pericial, e argumenta a operação de violação ao princípio do contraditório, pois a defesa técnica fora alijada da possibilidade de averiguar arquivos digitais arrecadados na investigação preliminar.

Sustenta a falta de provas de autoria delitiva e suscita a desnecessidade da prisão cautelar, inclusive sob o argumento de excesso de prazo de duração da custódia.

Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o reconhecimento da ilicitude das provas que embasam a sentença, com a consequente despronúncia do paciente.

Manifesta interesse na realização de sustentação oral.

A liminar foi indeferida às fls. 3.151/3.155.

O Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Parobé/RS prestou informações pelo Ofício n. 10058233388 (fls. 3.160/3.162).

O Ministério Público Federal, às fls. 3.167/3.171, ofertou parecer pela denegação da ordem.

Pedido de preferência (fls. 3.174/3.180).

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 3.182/3.190).

É o relatório.

Decido.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, tem restringido a admissibilidade de *habeas corpus* substitutivo do meio próprio de impugnação, resguardada a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando identificada flagrante ilegalidade ou teratologia.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado, exemplificativo do entendimento referido:

**AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTAS PRÁTICAS
DELITIVAS CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.**

**1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de
não admitir habeas corpus em substituição a recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em**

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. Precedentes.

2. O trancamento da ação penal ou do inquérito policial deve ocorrer tão somente nos casos em que houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre no presente caso.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 833.227/MG, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Portanto, não se conhece do *habeas corpus* substitutivo de recurso próprio.

Contudo, a fim de conferir máxima efetividade ao princípio da ampla defesa, promovo o exame da controvérsia para remediar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Cumpre registrar que o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, dispõe que o Ministro Relator pode "*decidir o habeas corpus quando for inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar*" (art. 34, XX, RISTJ). Do mesmo modo, admite-se o julgamento monocrático de questões pacificadas, conforme o enunciado 568 da Súmula do STJ, pelo qual "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Como relatado, busca-se a despronúncia do paciente, sob o argumento de quebra da cadeia de custódia e consequente ilegitimidade do material epistêmico que ampara a sentença. Objetiva-se, também, a revogação da segregação imposta ao agente.

Para melhor compreensão da matéria controvertida, colhe-se das informações encaminhadas pelo Juízo de primeiro grau que:

"Em atendimento à decisão proferida no *Habeas Corpus* n° 902195/RS (2024/0110552-3), informo que o paciente **MARIZAN DE FREITAS teve a prisão preventiva decretada 06/11/2019, com fundamento na garantia da ordem pública, no risco de reiteração criminosa e para conveniência da instrução criminal (evento 4,**

PROCJUDIC7, págs. 32/35).

Foi oferecida denúncia em desfavor do réu, imputando-o como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, cumulado com o artigo 61, inciso I e artigo 62, inciso I, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal (evento 4, PROCJUDIC1, págs. 02/05).

A denúncia foi recebida em 06 de novembro de 2019.

Citados, os réus ofereceram respostas à acusação.

No curso da instrução foram ouvidas seis testemunhas arroladas pela acusação e interrogados os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou memoriais, em que afirmou estarem comprovadas a materialidade e a autoria do delito, requerendo a pronúncia dos réus, nos termos da denúncia.

As defesas, por seu turno, apresentaram memoriais. A defesa de Gilberto discorreu sobre a ausência de indícios autorais, requerendo sua impronúncia, nos termos do artigo 414, do CPP. A defesa da Marizan pugnou pela impronúncia, diante da inexistência de provas de sua participação no delito em comento.

Sobreveio sentença de pronúncia (evento 4, PROCJUDIC21, pág. 50 e evento 4, PROCJUDIC22, págs. 01/06).

A Defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito (evento 4, PROCJUDIC22, págs. 18/21), o qual foi recebido (evento 4, PROCJUDIC23, pág. 18).

O recurso foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença de pronúncia.

A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento, restando indeferido o pleito defensivo.

Foram intimadas a Acusação e as Defesas a se manifestarem acerca das testemunhas a serem inquiridas em plenário, na forma do artigo 422 do CPP.

A Defesa de Marizan requereu a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar humanitária, entendendo este Juízo ser da Vara de Execução Criminal a competência para apreciação do pleito, não se opondo, contudo, ao eventual deferimento exarado pela VEC (evento 105, DESPADEC1).

Sobreveio informação oriunda do Juízo da Vara de Execução Criminal de que havia sido concedida a prisão domiciliar humanitária ao paciente, pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias, sendo mantida, por este Juízo, a não oposição quanto ao deferimento (evento 130, DESPADEC1).

Foi informado nos autos a fuga do paciente e sua recaptura no Estado de São Paulo, restando revogada a prisão domiciliar concedida.

Veio ao processo decisão exarada em Habeas Corpus impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça, que concedeu prisão domiciliar ao paciente, sendo determinada, por este Juízo, a expedição de ofício à Corte

Superior para fim de dar ciência ao Eminentíssimo Relator acerca da recente fuga e captura do acusado (evento 183, DESPADEC1).

Sobreveio decisão proferida no Habeas Corpus com a informação de que havia sido revogada a prisão domiciliar ao paciente (evento 200, DECSTJSTF2).

Em razão disso, restou mantida a prisão preventiva do paciente, tal qual decretada nos autos (evento 206, DESPADEC1).

Sobreveio decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2023, em que foi determinado o cancelamento da sessão plenária do Tribunal do Júri aprazada para 06/12/2023 para que fosse previamente realizada perícia no aparelho celular apreendido (evento 341, ACSTJSTF1)

Foi realizado o encaminhamento do telefone celular ao Instituto-Geral de Perícias, sendo possibilitada à acusação e à defesa a indicação de assistente técnico (evento 367, DESPADEC1).

Aportou aos autos o laudo pericial realizado pelo IGP, oportunidade em que foi certificado que o aparelho não apresentou condições de funcionamento quando submetido à perícia (evento 397, LAUDO1).

Dada vista às partes, a defesa do paciente requereu a sua despronúncia (evento 404, PET1), bem como a concessão da sua liberdade provisória; o Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo prosseguimento do feito com designação do Tribunal do Júri e pela manutenção da prisão preventiva do paciente (evento 413, PARECER1).

Foram indeferidos os pedidos de despronúncia e de liberdade provisória formulados pela defesa (evento 415, DESPADEC1).

Na data de hoje, deferi o pedido de admissão de assistentes técnicos formulado pela defesa do réu Marizan de Freitas, abrindo prazo para apresentação de quesitos complementares.

Ainda, os autos aguardam, também, a preclusão da decisão que indeferiu o pedido de despronúncia para o novo aprazamento da sessão plenária." (fls. 3.160/3.162 - grifos adicionados).

O Tribunal de origem, por sua vez, conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou a ordem impetrada, da seguinte forma:

"Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente **MARIZAN DE FREITAS, recolhido preventivamente desde 11/11/2019, por suposto envolvimento com o crime descrito no artigo 121, §2º, I e IV, do CP.**

Quando do exame liminar, proferi decisão indeferindo-o (evento 4, DOC1).

No mérito, após análise casuística do feito e do parecer apresentado pela Procuradoria de Justiça, tenho que é caso de denegar a ordem.

Afora o esgotamento do tema quando do exame liminar do pedido, reforço que a custódia cautelar do paciente não pode ser revogada no presente caso, diante da sua conduta em liberdade se manifestar como elemento de perigo à ordem pública.

MARIZAN possui um extenso histórico criminal, estando em cumprimento de uma pena total de 43 anos e 07 meses de reclusão, com saldo de mais de vinte e nove anos a cumprir. Não somente isso, quando recentemente agraciado com a prisão domiciliar, buscou se furtar tanto da execução de sua pena quanto de sua responsabilização criminal em processos pelos quais está respondendo. Na oportunidade, a sua tentativa de fuga se tornou notória, tendo sido localizado quando estava no estado de São Paulo, com informações obtidas pela Secretaria de Segurança Pública de que orquestrava a saída do Brasil para o Peru. Todas condições, quando somadas, expõem a periculosidade em concreto do paciente.

Sob outro aspecto, não prospera a alegação de excesso de prazo à formação da culpa do paciente. Isso porque a delonga no feito tem se dado diante do cumprimento de diligências requeridas pela própria defesa, as quais estão sendo, inclusive, efetivadas em tempo hábil pelo Juízo a quo e demais autoridades competentes para o prosseguimento do feito e submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, vale lembrar que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, os quais se encontram presentes.

Nesse contexto, a busca defensiva pela declaração de ilicitude das provas obtidas pelo resultado da extração de dados e, posterior, despronúncia do acusado, com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal, revela-se inexequível diante do quadro fático apresentado quando do exame liminar, bem como em face da inviabilidade de se aprofundar em questões de mérito em sede de habeas corpus.

Urge destacar, por relevante, que a interpretação desta corte possui um limite de cognição, pela simples razão de que o colegiado desta Câmara entendeu de confirmar a sentença de pronúncia, decisão que se encontra preclusa.

Ainda que tenha a parte obtido, junto à instância especial, o direito de produzir prova, ou de aprofundar os meios técnicos decorrentes da extração de dados do aparelho celular da vítima, e que essa diligência tenha restado prejudicada por questões técnicas, esta Câmara não pode revogar seus próprios julgados em um Habeas Corpus. As implicações da perda dessa prova só podem ser controvertidas na instância especial, não no mesmo foro que, com base nesses mesmos elementos, confirmou a pronúncia, dificuldade operacional que se reputa insuperável,

No mais, o fato delituoso em apreço ocorreu em 2018, tendo o impetrante assumido a defesa do paciente em 02/05/2022 (evento 12, DOC1 e evento 9, DOC1), posteriormente à decisão de pronúncia e durante o julgamento do Recurso em Sentido Estrito contra ela interposto, sendo que a tese de nulidade absoluta da prova consistente na extração de dados sem perícia somente foi aduzida em sede embargos de declaração, sequer conhecida pelo Desembargador Luiz Mello Guimarães (evento 45, DOC1).

Apesar da impossibilidade atual de acesso aos elementos de prova objetos de contestação, não se pode presumir a ilegalidade dos relatórios e da extração de dados operada, posto que produzidos à época em que não se exigiu a adoção de procedimento específico para a sua realização. Logo, não há como se ignorar o significativo lapso temporal havido entre a apreensão do telefone celular - quando sequer eram regulamentados os procedimentos atinentes à cadeia de custódia - e a pretensão de acesso pela defesa aos dados constantes nele. Pelo que se depreende, a defesa permaneceu inerte acerca desse material probatório por aproximadamente 04 anos, somente o contestando após a preclusão da sentença de pronúncia.

Inclusive, a decisão proferida pela Corte Superior no âmbito do Habeas Corpus nº 856.121 reconheceu a mitigação ao princípio do contraditório, tão somente afirmando que seria necessário viabilizar o pleno exercício da prerrogativa profissional do causídico do paciente, consistente em conhecer dos dados probatórios formalmente produzidos no âmbito da investigação, que digam respeito ao exercício legítimo do direito de defesa. No entanto, neste decisum, o Superior Tribunal de Justiça também concluiu que a prova trazida aos autos é íntegra, inexistindo qualquer indício adulteração do material probatório juntado ao feito.

Com efeito, sendo a irresignação defensiva direcionada à decisão de pronúncia, a qual restou confirmada por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, a controvérsia aqui despertada não pode ser deduzida por habeas corpus na mesma instância confirmatória do ato pronunciatório. Tal circunstância demanda o não conhecimento da impetração no ponto, seja pela inadequação da medida quanto ao endereçamento de sua contestação, como também pela preclusão da matéria, em face do trânsito em julgado da decisão de pronúncia.

Destarte, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no decreto prisional, sendo o exame da repercussão da prejudicialidade da prova ao juízo de pronúncia inoportuno neste momento processual, a repercutir, tão somente, a resistência defensiva em aceitar a preclusão da sentença.

Por tais fundamentos, voto por conhecer em parte do writ e, na parte conhecida, por denegar a ordem. " (fls. 124/125 - grifos adicionados).

Previamente ao exame do mérito do *writ*, cumpre consignar que "[o] **instrumento do habeas corpus é cabível para o reconhecimento de nulidades no curso da investigação ou da correspondente ação penal, mormente consubstanciada na ilicitude de elementos de prova.** Isso porque a hipótese releva cenário de manifesto constrangimento ilegal passível de reconhecimento, ainda que por dever de ofício, pelo Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no RHC n. 167.539/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DJe de 15/12/2023).

Firmada essa premissa, quanto à controvérsia relativa ao material probatório, anoto que "[o] **instituto da cadeia de custódia visa a garantir que o tratamento dos elementos probatórios, desde sua arrecadação até a análise pela autoridade judicial, seja idôneo e livre de qualquer interferência que possa macular a confiabilidade da prova**" (AgRg no HC n. 828.054/RN, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe de 29/4/2024).

Além disso, "[a] **jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até, especialmente, a sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a tramitação pode resultar, mas não necessariamente, em imprestabilidade para o processo de referência [...]**" (AgRg no RHC n. 187.376/SP, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DJe de 16/5/2024).

Como visto, a Corte estadual entendeu pela impossibilidade de deliberação acerca da alegada ilegitimidade das provas extraídas de aparelho celular, bem como da despronúncia do agente, tendo em vista o limitado espectro de cognição do *habeas corpus* associado ao fato de que aquele Tribunal já decidiu, definitivamente, sobre a sentença de pronúncia. Acrescentou que ao tempo da investigação não eram regulamentados os procedimentos atinentes à cadeia de custódia. Decidiu, ainda, que a defesa permaneceu inerte por razoável período de tempo e alegou a nulidade em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou recurso em sentido estrito, sujeitando-se aos efeitos da preclusão.

De fato, o entendimento do Tribunal relativo à incidência das regras da cadeia de custódia encontra amparo em precedentes desta Corte, a conferir:

**AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E
V; ART. 157, § 2º-A, INCISO I; ART. 304, C/C O ART. 297,
NA FORMA DO ART. 29; ART. 311; E ART. 288,
PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO**

DE DADOS EXTRAÍDOS PELA SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA (SSINTE). ALEGADA USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, CONSISTENTE EM CONVERSAS DE WHATSAPP EXTRAÍDAS DE OUTROS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ACESSO DE DADOS ANTES DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. **DESCONHECIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM.** AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

5. No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2º do CPP, que: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje".

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Nada obstante, mesmo considerado que especificidades do regramento legal da cadeia de custódia não retroajam, o STJ tem decidido que: "[...] a necessidade de preservar a cadeia de custódia não surgiu com eles. Afinal, a ideia de cadeia de custódia é logicamente indissociável do próprio conceito de corpo de delito, constante no CPP desde a redação original de seu art. 158. Por isso, mesmo para fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia" (AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

Além disso, todavia não alegada durante a primeira fase do procedimento do júri, a tese de ilicitude de prova constante da decisão de pronúncia, manifestada na fase do art. 422 do CPP, como feito pela defesa, deve ser conhecida, assegurando-se a possibilidade de verificação da integridade e autenticidade de elementos de cognição eventualmente utilizados na sentença, como decidido no HC 856.121/RS.

Desse modo, tem razão a defesa ao alegar a impossibilidade de averiguar a existência, a integridade e o contexto em que teriam sido trocadas mensagens que constituiriam parte do arcabouço probatório que ampara a persecução penal.

Em corroboração, convém ressaltar as considerações de Daniel Salgado sobre a qualidade do material probatório submetido à valoração no processo:

"Dessarte, no processo penal, em que se tem a verdade como indicador epistêmico e, sobretudo, sendo ele o caminho para possível restrição da liberdade do indivíduo, mister que a atividade probatória seja ampla, a viabilizar, dentro de um procedimento dialético, o maior acúmulo de informações, incluindo aquelas que possam resultar necessárias à valoração adequada da eficácia probatória dos elementos individualmente produzidos. Para se alcançar o melhor conjunto probatório possível, é de extrema relevância a qualidade do material probatório, a ser aferida, inclusive, por meio da prática de outras provas que coloquem em relevo maior ou menor grau de fiabilidade das provas diretamente dirigidas aos enunciados fáticos, objeto do processo, conferindo, assim, a mais elevada segurança epistêmica ao julgador. Noutros termos, é necessário um esforço do sistema de justiça pela melhor prova possível, fato que reflete na necessidade de excelente investigação e da preparação cuidadosa e completa dos elementos de informação e das provas, com o escopo de superar a presunção de inocência, mormente em face da escolha axiológica em privilegiar a liberdade".

(SALGADO, Daniel de Resende. **A metaprova no processo penal: seu perfil conceitual e funcional e o controle racional da fiabilidade da prova**. 2.ed. - São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 188).

No caso, como indicado pelo impetrante na inicial, o Instituto-Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul elaborou o Laudo Pericial n. 205297/2023. No documento consta que **"Na ocasião dos exames o CEL01 não apresentou condições de funcionamento. Foram feitas diversas tentativas de acesso ao conteúdo do dispositivo, utilizando diversos métodos, mas não foi possível efetivar o carregamento do sistema Android do aparelho. [...] Foi possível apenas extrair uma lista de contatos do chip SIM da operadora Claro (fls. 2.846/2.847).**

Nessa conjuntura, o material cognitivo considerado inadmissível deve ser desentranhado do feito na origem, tendo em conta o art. 157 do CPP. A propósito, confira-se julgado desta Corte Superior:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORNOGRAFIA

INFANTIL. ART. 241-B DO ECA. DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS SEM O MENOR RIGOR TÉCNICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA. PRECEDENTE DESTES COLEGIADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A principal finalidade da cadeia de custódia, enquanto decorrência lógica do conceito de corpo de delito (art. 158 do CPP), é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Isto é: busca-se assegurar que os vestígios são os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado.

2. A falta de documentação mínima dos procedimentos adotados pela polícia no tratamento da prova extraída de aparelhos eletrônicos, bem como a falta de adoção das práticas necessárias para garantir a integridade do conteúdo, torna inadmissível a prova, por quebra da cadeia de custódia. Entendimento adotado por esta Quinta Turma no julgamento do AgRg no RHC 143.169/RJ, de minha relatoria, DJe de 2/3/2023.

3. Como decidimos naquela ocasião, "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.342.908/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).

Apesar disso, ainda que a defesa alegue a insuficiência de conteúdo probatório independente e suficiente para sustentar a pronúncia, diante dos limites cognitivos desta via, é inviável o exame acurado do feito para fins de identificar a extensão e a repercussão, na persecução penal, da ilegitimidade probatória constatada, considerando-se, inclusive, que esse tema nem sequer foi deliberado no acórdão contestado.

Além do óbice da supressão de instância, a verificação da subsistência de elementos de convicção autônomos hábeis a sustentar a sentença dependeria de incursão no contexto fático e probatório. É dizer, não há como concluir se os elementos probatórios cuja imprestabilidade ora se reconhece representam a integralidade do arcabouço epistêmico que subsidia a ação penal.

Dessa maneira, reconhecida a nulidade da utilização e a impossibilidade de

menção, nos autos, aos elementos de convicção ilegítimos, incumbirá ao Juízo singular identificar as provas cuja utilização é proscrita e o conteúdo delas derivado, na forma prevista no art. 157 e §§ do CPP, devendo invalidá-las. Na sequência, descartados todos os elementos imprestáveis, deverá averiguar se persistem outros que, obtidos por fonte totalmente independente ou cuja descoberta seria inevitável, possibilitem eventual prosseguimento da ação penal, revelando-se imprescindível a renovação de ato processual, nos termos do art. 573 do CPP.

A propósito, confirmam-se julgados cujas razões de decidir aplicam-se, *mutatis mutandis*, à espécie:

HABEAS CORPUS. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INVESTIGAÇÃO INICIADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. POSTERIOR DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PELA POLÍCIA FEDERAL. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE CONTINUIDADE PELA POLÍCIA CIVIL. NULIDADE. ILEGALIDADE CONSTATADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar a possibilidade de prosseguimento da investigação pela Polícia Federal, mesmo após o declínio da competência para o processamento do feito para a Justiça Estadual.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a ausência de nulidade quando a investigação tem início perante uma autoridade policial, com a consequente redistribuição do feito a outro órgão jurisdicional em razão da incompetência. Precedentes.

3. Todavia, no caso em análise, mesmo após a redistribuição do feito para a Justiça Estadual, motivada pela declaração de incompetência do Juízo Federal, a investigação continuou a ser presidida pela Polícia Federal, a despeito de determinação expressa do então detentor da jurisdição de encaminhamento do feito à Polícia Civil.

4. Embora não seja possível afirmar se a representação pela quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados antecedeu o declínio da competência em análise, é certo que as representações pelas prisões temporárias, buscas e apreensões e outras cautelares foram formuladas, pela Polícia Federal, quando os autos já estavam em trâmite perante a Justiça Estadual.

5. As circunstâncias descritas evidenciam a nulidade das investigações realizadas pela Polícia Federal a partir do declínio da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual.

6. Entretanto, na limitada via deste writ, não há como aferir, com precisão, se a ilegalidade aqui declarada macula por completo o inquérito policial ou se há elementos informativos autônomos que possam ensejar a continuidade das investigações.

7. Fica ressalvada a possibilidade de, mediante

devida provocação, autorizar o Juízo singular o compartilhamento das investigações pelas Polícias Civil e Federal. Todavia, a medida só será válida a partir do momento em que proferida decisão judicial nesse sentido.

8. Ordem concedida para reconhecer a ilegalidade, por falta de atribuições, das investigações realizadas pela Polícia Federal, no Inquérito Policial Federal n. 2021.19806, a partir do declínio da competência da Justiça Federal para a Justiça Estadual, ocorrida em 26/4/2021. Deverá Juízo de primeiro grau, após descartar todos esses elementos viciados pela ilegalidade: a) averiguar se há outros obtidos por fonte totalmente independente ou cuja descoberta seria inevitável a permitir o prosseguimento do feito; b) cumprir a determinação, exarada em 26/4/2021, de envio dos autos à Polícia Civil, para continuidade das investigações.

(HC n. 772.142/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2023, DJe de 3/4/2023).

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.

2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.

3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.

4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e costituzione. Giuffrè: Milano,

1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação."

5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes.

6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.

7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto.

(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DE PROVAS. CARACTERIZADA. ACESSO AO APARELHO CELULAR DE UM DOS RÉUS. REDISCAGEM PARA O ÚLTIMO NÚMERO DE CHAMADAS PERDIDAS. INVIOABILIDADE DOS DADOS. SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA COLHEITA DE DADOS RECONHECIDA. DESENTRANHAMENTO DA PROVAS DERIVADAS. ANÁLISE DO NEXO DE CAUSALIDADE E EVENTUAL EXISTÊNCIA DE FONTE INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de nulidade de provas foi destramada pela Corte Regional ao argumento de que a proteção constitucional, regulamentada pela Lei n. 9.296/1996, não abrangeria as hipóteses em que efetuada a constatação de dados pretéritos já registrados no aparelho de telefone celular, sendo que a mera visualização de registros telefônicos, áudios, vídeos e mensagens de texto salvas na memória do celular não caracterizaria interceptação telefônica, não ensejando afronta à garantia da inviolabilidade das comunicações.

2. No caso concreto, os policiais acessaram o celular de RODRIGO, condutor do veículo Fiesta, placas AGH-8491, que transportava os objetos ilícitos, e não apenas visualizaram o histórico de chamadas, como também rediscaram para o último número das chamadas perdidas, o que permitiu inferir a participação de MÁRCIO e

LUCIANO, que viajavam em outro veículo, nos fatos.

3. O aresto hostilizado destoa da orientação desta Corte, pois, "Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, relativamente à ilicitude da prova, são invioláveis os dados armazenados nos aparelhos celulares, cujo acesso apenas pode ocorrer mediante prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do agente" (HC 542.293/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 19/12/2019).

4. Caso em que deve ser reconhecida a ilicitude da colheita de dados do aparelho telefônico, devendo a mencionada prova, bem como as derivadas, serem desentranhadas dos autos, competindo ao magistrado de primeiro grau analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.912.303/PR, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Por fim, não há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, como bem observou o MPF, assim argumentando:

"[...] quanto à prisão cautelar, este órgão ministerial se limita a reproduzir os fundamentos lançados pela Corte estadual, os quais demonstram o risco concreto à ordem pública ante a elevada periculosidade do acusado e a não configuração de indevido excesso de prazo na formação da culpa (fl. 102):

"[...] não vislumbro qualquer mácula aos elementos que amparam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantendo-se impositiva a segregação cautelar do acusado, sobre a qual já me manifestei previamente, inclusive afastando a tese de excesso de prazo novamente sustentada. Rememoro que a dilação do prazo à formação da culpa do paciente decorre de providências requeridas pela própria defesa que, mesmo que não sejam impertinentes, estão sendo realizadas pelo Juízo a quo e demais autoridades competentes em tempo hábil para o prosseguimento do feito e submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim, a alegação de excesso de prazo não pode ser analisada de forma dissociada da periculosidade em concreto apresentada pelo paciente, o qual, além de estar respondendo pela prática de delito de extrema gravidade, ostenta condenações pretéritas por delitos graves, como homicídio tentado, tráfico e organização criminosa, bem como de associação para o tráfico de drogas. Frente a estes dados, observa-se que o paciente possui um histórico criminal extenso, não estando apenas recolhido diante da prisão preventiva decretada nos autos do processo originário deste writ, como também por estar em cumprimento das reprimendas que lhe foram impostas, de uma pena total de 43 anos e 07 meses, com saldo a cumprir de 29 anos e 02 meses aproximadamente (PEC nº 6284339-35.2010.8.21.0019)." (fl. 3.171).

Acrescento que permanecem híidas as razões de decidir desenvolvidas no HC n. 760.946/RS e no HC 856.121/RS, acerca do cabimento da prisão preventiva, não se

viabilizando mais um exame, pois não foram apontados fatos novos capazes de desconstituir a motivação e a fundamentação adotadas nas decisões referidas.

Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISJT, não conheço do *habeas corpus*, contudo, concedo a ordem, de ofício, parcialmente, para determinar o desentranhamento das provas obtidas da extração dos dados do aparelho celular do ofendido, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, determinando, ainda, que outra sentença seja proferida.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 12 de agosto de 2024.

JOEL ILAN PACIORNIK

Relator